



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2017.0000852459

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000262-13.2016.8.26.0414, da Comarca de Palmeira D Oeste, em que é apelante IVAIR MONTANARI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.

Consolidado o entendimento do Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária de 05 de outubro de 2016, daquele que prevaleceu no HC nº 126.292/SP (Relator Ministro Teori Zavascki), no sentido de que, exaurida a possibilidade de tramitação de recursos em Segunda Instância, ainda que pendentes Recursos Especial e Extraordinário sem efeito suspensivo, possível a determinação de início imediato do cumprimento da pena, determinaram a expedição de mandado de prisão após certificada a não interposição de recursos ordinários da presente decisão. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERNANDO SIMÃO (Presidente sem voto), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.

São Paulo, 1º de novembro de 2017.

ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Apelação nº 0000262-13.2016.8.26.0414

Apelante: Ivair Montanari

Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Comarca: Palmeira D Oeste

Voto nº 8476

APELAÇÃO — LESÕES CORPORAIS — VIOLÊNCIA DOMÉSTICA —ARTIGO 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL — APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 542/STJ — NECESSIDADE —CONFIGURAÇÃO —OCORRÊNCIA — ABSOLVIÇÃO — IMPOSSIBILIDADE — LEGÍTIMA DEFESA — CARACTERIZAÇÃO — INOCORRÊNCIA — APENAMENTO — PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE — MITIGAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE — SUBSTITUIÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO — IMPOSSIBILIDADE — SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS — IMPOSSIBILIDADE — PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA —RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO.

Ivair Montanari foi condenado à pena de 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, por infringência do artigo 129, § 9º, do Código Penal, pela r. sentença de fls. 135/140, que julgou procedente a presente ação penal. Foi-lhe facultado o direito de recorrer em liberdade.

Irresignado busca o apelante, em resumo, a reforma da sobredita r. sentença, com sua absolvição da imputação irrogada na denúncia, pelo reconhecimento da configuração da excludente da legítima defesa, nos termos do artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, postula: [1] a mitigação das penas para alguém do mínimo legal; [2] a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito (fls. 142/148).

O recurso foi contra-arrazoado (fls. 156/157), tendo a douta Procuradoria Geral de Justiça opinado no sentido do improvimento do recurso interposto (fls. 166/170).

É o relatório.

Inconsistente a inconformidade recursal manifestada.

“In casu”, a materialidade delitiva dos fatos delituosos encontra-se devidamente demonstrada pelos autos de: boletim de ocorrência (fls. 05/06); laudo de exame de corpo de delito (fls. 15/16; 21/22 – lesões de natureza leve). A vítima não apresentou representação (fls. 07), todavia, é a hipótese de aplicação do enunciado da Súmula nº 542/STJ: *“A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada.”* (j. 26.08.2015, DJe 31.08.2015).

No mais, na hipótese em tela, em estrita observância do princípio constitucional da razoável duração do processo (CF/88, artigo 5º, inciso LXXVIII) e do princípio constitucional da eficiência (CF/88, artigo 37), alinhado com o pacificado entendimento do Supremo Tribunal Federal (ED ARE nº 723.254/SP, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, v.u., j. 14.04.2015, DJe 84; STF, AgR ARE nº 727.030/RS, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, v.u., j. 19.11.2013, DJe 237; QO-RG AI nº 791.292/PE, Relator Ministro Gilmar Mendes, j. 23.06.2010, Repercussão Geral – Mérito, *Ementário* 2410-6/1289), assim como o permissivo do artigo 252 do Regimento Interno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, aplica-se a técnica da fundamentação *“per relationem”*, pela qual o Magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior, em vista da constatação de a r. sentença ter examinado

percucientemente todos os elementos do conjunto fático-probatório:

“O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido de que o crime de lesão corporal leve, no contexto da violência doméstica, familiar ou afetiva contra a mulher, hipótese dos autos, prescinde de representação (ADI 4.424 e a ADC 19), por se tratar, na hipótese, de ação penal pública incondicionada.

A materialidade está comprovada pelo boletim de ocorrência (fl. 5/6), laudo pericial (fl. 15/16), bem como pelos depoimentos colhidos.

No laudo do exame de corpo de delito, o perito constatou hematoma na região arco zigomático direito, no couro cabeludo a direita, e edema lateral da coxa esquerda, concluindo que a vítima sofreu lesões corporais de natureza leve (fl. 15/16).

A autoria também é indubitosa.

Na fase policial, a vítima narrou que, convive com o acusado por mais de um ano. Na data dos fatos, durante o dia, ligou para ele e ele a ofendeu. À noite, quando ele chegou, foi chamar-lhe a atenção pela maneira que foi tratada, mas ele ficou nervoso e bateu a mão em algumas panelas que estavam sobre o fogão, jogando tudo no chão. Estava recolhendo roupas no varal, dentro da área de serviços, quando o acusado arremessou uma garrafa de vinho, da qual conseguiu se desviar. Ele entrou em casa e pegou um arpão, dizendo que se ela tentasse entrar ele atiraria o objeto. Ele estava com um copo de vinho nas mãos e jogou o líquido no rosto da vítima. Nervosa com essa atitude, cuspiu contra ele. Então, ele a agarrou pelo pescoço com um golpe de braço chamado 'gravata' e começou a desferir socos contra o seu rosto. Para se livrar, mordeu o braço dele, momento em que foi solta. Mas, mesmo assim, ele ainda acertou as suas pernas com chutes. Comunicou à polícia, que compareceu ao local (fl. 7).

Ainda na delegacia de polícia, os policiais

militares Claudio Renato Sardins e Voneis José dos Santos alegaram que, na data dos fatos, foram acionados por uma colega da cidade de São Francisco, dizendo que a vítima havia ligado e informado ter sido agredida por seu companheiro. Compareceram no local e tanto a vítima como o autor disseram terem sido agredidos e apresentavam lesões. Diante do ocorrido, foram conduzidos até o PS da cidade (fl. 17/18).

Na mesma sede, o acusado alegou que no dia do ocorrido foi esquentar seu jantar enquanto a vítima assistia à televisão. Quando ela percebeu, foi em direção dele brava e começou a discutir. Sem querer, ele esbarrou em uma panela de feijão e a derrubou. Quando estava tomando um copo de vinho, a vítima pegou a garrafa e a quebrou. Logo depois, ela lhe mordeu o braço, quando desferiu um chute nela. Com medo de ela pegar uma faca, acabou se trancando dentro de casa, deixando ela do lado de fora. Então, ela começou a dizer que iria 'ferrá-lo', pois chamaria a polícia e diria que ele tentou matá-la, bem como pediria indenização (fl. 19).

Em Juízo, a vítima e a testemunha Voneis José dos Santos confirmaram seus relatos anteriores.

Interrogado em Juízo, o acusado sustentou sua versão. Em acréscimo, reconheceu que agarrou a vítima e desferiu tapas e socos contra ela. Disse que, no momento em que a agarrou, apenas quis se defender.

Saliento que o depoimento da vítima ganha especial relevo e autoriza o decreto condenatório, desde que robustecido pelos demais elementos e provas dos autos, sobretudo porque a infração penal em exame costuma ser perpetrada no ambiente particular, raras vezes perante testemunhas presenciais.

No caso vertente, o depoimento da vítima na delegacia foi reforçado pelo laudo pericial, cujas conclusões correspondem às agressões que ela alegou ter suportado.

De outra parte, a legítima defesa ficou

descartada.

Primeiro porque, embora na delegacia de polícia tenha reconhecido que deu um chute contra a vítima, o que, segundo ela, atingiu as suas pernas, não conseguiu explicar a origem das outras lesões nela constatadas, notadamente o hematoma na região arco zigomático direito e no couro cabeludo (fl. 15/16). As lesões confirmam a versão dela de que ele desferiu socos contra o seu rosto.

Segundo porque a lesão constatada no acusado, ou seja, marca de dente na fase do bíceps esquerdo (fl. 21/22), revela-se mais compatível com as declarações da vítima no sentido de que ela mordeu o braço dele para se livrar do golpe de 'gravata', que ele havia aplicado. Assim, a toda evidência, se legítima defesa houve, foi por parte da vítima, e não do acusado.

Ademais, o próprio réu afirmou que agarrou a vítima e desferiu socos contra a sua cabeça.

Ora, mesmo que verdadeira a versão apresentada pelo acusado, é de se pressupor que, se o réu já tinha agarrado a vítima, os socos contra a sua cabeça eram desnecessários, pois ela estava dominada.

Assim sendo, de toda a sorte, houve excesso punível (CP, art. 23, parágrafo único).

A dinâmica dos fatos revela que a infração penal foi perpetrada no contexto da violência doméstica, afetiva ou familiar contra a mulher, incidindo, portanto, a respectiva qualificadora.

Destarte, suficientemente comprovado que o réu incorreu no art. 129, § 9º, do CP."

(fls. 136/139).

A versão da vítima é corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito, que atestou a existência de lesões leves no corpo da vítima Ana Geralda Santos Coimbra (fls. 15/16; 21/22).

Assim, com base nas firmes e coerentes declarações da vítima, que vieram ratificadas pela prova técnica, conclui-se que o apelante, efetivamente a agrediu, provocando-lhe as várias lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito. Ressalte-se que, no caso de lesões corporais praticada contra mulher, em situação de violência doméstica e / ou familiar, as palavras da vítima revestem-se de elevada força probatória, ainda mais quando a versão por ela apresentada, durante a fase administrativa e em Juízo, é amparada pelas demais provas dos autos, impossibilitando o eventual pleito de absolvição por insuficiência e fragilidade dos elementos do conjunto probatório dos autos.

O Supremo Tribunal Federal e o Colendo Superior Tribunal de Justiça respaldam o entendimento acima exposto:

“Ementa: AGRADO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRADO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE AMEAÇA. ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287/STF. PRECEDENTES. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO.

1. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz à inadmissão do recurso extraordinário. Súmula 287 do STF. Precedentes: ARE 680.279-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22/5/2012, e ARE 735.978-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/9/2013.

2. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: 'APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER – LEI MARIA DA PENHA – CRIME DE AMEAÇA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVANTE VALOR – AUTORIA E MATERIALIDADE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

COMPROVADAS – RECURSO IMPROVIDO.'

3. Agravo regimental DESPROVIDO."

(STF, AgR ARE nº 855.292/ES, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, v.u., j. 10.02.2015, DJe 45).

"LESÕES CORPORAIS PRATICADAS EM AMBIENTE DOMÉSTICO OU FAMILIAR. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ÉDITO REPRESSIVO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. [...]

3. Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, em que geralmente não há testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, não podendo ser desconsiderada, notadamente se está em consonância com os demais elementos de prova produzidos nos autos, exatamente como na espécie. Precedentes.

[...]

5. Habeas corpus não conhecido."

(STJ, HC nº 318.976/RS, Relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador convocado do TJ/PE], Quinta Turma, v.u., j. 06.08.2015, DJe 18.08.2015).

No mesmo sentido: STJ, AgRg no AREsp nº 423.707/RJ, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, v.u., j. 07.10.2014, DJe 21.10.2014; STJ, RHC nº 34.035/AL, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, v.u., j. 05.11.2013, DJe 25.11.2013.

Quanto ao pleito de reconhecimento da configuração da excludente da legítima defesa, este não encontra respaldo no conjunto probatório carreado aos autos.

Dever ser ressaltado que age em legítima defesa quem repudia agressão injusta, atual ou iminente, a direito próprio ou de terceiro, com uso moderado de meios necessários, sendo certo que tais requisitos, dispostos no artigo 25 do Código Penal, devem estar presentes de forma concomitante. Assim sendo, para se caracterizar a legítima defesa, seria preciso que o réu repelisse a injusta agressão da vítima, com o uso necessário e moderado dos meios, o que não se verificou na presente hipótese (conforme o relato da vítima Ana Geralda Santos Coimbra, em Juízo – fls. 120/122; mídia digital em anexo físico).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça endossa o posicionamento acima consignado:

“HABEAS CORPUS. LESÕES CORPORAIS SEGUIDAS DE MORTE (ARTIGO 129, § 3º, DO CÓDIGO PENAL). PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. APONTADA EXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE ANTIJURIDICIDADE (LEGÍTIMA DEFESA). NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT.

1. A alegada atuação do paciente em legítima defesa, a ensejar a pretendida absolvição, é questão que demanda aprofundada análise de provas, o que é vedado na via estreita do remédio constitucional, que possui rito célere e desprovido de dilação probatória.

2. No processo penal brasileiro vigora o princípio do livre convencimento, em que o julgador, desde que de forma fundamentada, pode decidir pela condenação, não cabendo, na angusta via do writ, o exame aprofundado de prova no intuito de reanalisar as razões e motivos pelos quais as instâncias anteriores formaram convicção pela prolação de decisão repressiva em desfavor do paciente.”

(STJ, HC nº 152.775/PR, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, v.u., j. 16.08.2011, DJe

01.09.2011).

No mesmo sentido: STJ, AgRg no AREsp nº 585.293/DF, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, v.u., j. 04.11.2014, DJe 17.11.2014.

Assim sendo, o conjunto probatório dos autos aponta para o increpado como o autor do delito atribuído a ele. O ônus da prova, quanto ao alegado pelo ora recorrente, cabia à sua Defesa (nesse sentido: STF, HC nº 96.099-5/RS, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 19.02.2009, *LEXSTF* vol. 31, nº 367, 2009, págs. 410/427; STF, HC nº 68.964-7/SP, Relator Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, v.u., *Ementário* 1741-3/444; STF, HC nº 70.742-4/RJ, Relator Ministro Carlos Velloso, Segunda Turma, *Ementário* 1997-2/251), na forma preconizada no artigo 156 do Código de Processo Penal, que dispõe que o ônus da prova incumbe a quem a alega, que não se desincumbiu dessa tarefa (fls. 142/148), reforçando, desse modo, a imputação assacada pela Justiça Pública.

No que tange à pena cominada, foi adequadamente dimensionada, com cuidadosa ponderação dos elementos fático-probatórios na dosimetria e na adequada motivação, em estrita observação da garantia de individualização da reprimenda (nesse sentido: STF, HC nº 72.435-3/SP, Relator Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, v.u., *Ementário* 2369-4/801; STF, RHC nº 96.541/RJ, Relator Ministro Ayres Britto, Segunda Turma, v.u., *Ementário* 2599-2/140), não havendo retificação alguma para ser realizada, por ter sido criteriosamente observado o método trifásico (disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal) —fls. 139 —, nem motivos para sua mitigação.

Quanto ao pleito do recorrente Ivair, de aplicação da atenuante da confissão espontânea, este não comporta recepção,

devendo ser ressaltado que não é possível, em razão da incidência de atenuante, operar redução que importe na fixação da pena abaixo do seu mínimo legal, conforme o teor da Súmula nº 231/STJ e pela observação de que tal pedido ofende o critério trifásico de cálculo da sanção, previsto no artigo 68 do Código Penal, pois, ao ser aplicado o sistema trifásico consideram-se as circunstâncias agravantes e atenuantes — exatamente porque circunstâncias, ou seja, periféricas — não existindo a possibilidade de se extravasar o máximo e, pela mesma lógica, tampouco reduzir-se a pena aquém do mínimo abstratamente previsto em lei para cada figura típica, sob pena de, em ambas as hipóteses, ofender-se a segurança jurídica, um dos princípios basilares do Estado de Direito.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal respalda o entendimento acima registrado:

“Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO EM GRAU MÉDIO (1/4). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL FECHADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – A jurisprudência pacífica desta Corte e do STJ é no sentido de que a incidência de circunstância atenuante não reduz a pena para aquém do mínimo legal.

II – O Tribunal Regional Federal da 1ª Região reformou a sentença condenatória para aumentar a fração de redução da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 para 1/4 (um quarto). A Corte regional deixou de aplicar o

redutor no grau máximo permitido por entender que o comportamento do recorrente apresentou um maior grau de reprovabilidade, diferente da conduta das chamadas 'mulas', haja vista ter adquirido a droga com seus próprios recursos, para posterior revenda.

III – Mantida a reprimenda no patamar superior a 4 (quatro) anos, fica superado o pedido de conversão da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, porquanto não atendido o requisito objetivo previsto no art. 44, I, do Código Penal. IV – A fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena imposta ao recorrente está em desconformidade com a Súmula 719 desta Corte, que estabelece que a imposição de regime mais gravoso do que a pena permite deve vir acompanhada da devida fundamentação, o que não ocorreu na espécie.

V – Recurso ordinário provido em parte, apenas para fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda imposta ao recorrente.”

(STF, RHC nº 118.996/AM, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, v.u., j. 18.02.2014, DJe 45).

No mesmo sentido: STF, HC nº 124.954/DF, Relator Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, v.u., j. 10.02.2015, DJe 65.

O apelante não faz jus ao benefício do artigo 44 do Código Penal, em face do inadimplemento dos **incisos I** (crime cometido com violência ou grave ameaça) e **III** (conduta social e personalidade do condenado não indicam que a substituição seria suficiente) do referido dispositivo legal; pelas mesmas razões, também não faz por merecer o benefício da suspensão condicional da pena – “*sursis*”.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça são pacíficas:

“Habeas corpus. 2. Lesão corporal leve praticada no âmbito doméstico ou familiar. Lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

11.340/2006. Condenação. Detenção. Pena inferior a 4 anos. Crime cometido com violência à pessoa. 3. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Impossibilidade. Art. 44, I, do CP. 4. Constrangimento ilegal não caracterizado. 5. Ordem denegada.”

(STF, HC nº 114.703/MS, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, v.u., j. 16.04.2013, DJe 81).

“VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ARTIGO 41 DA LEI Nº 11.340/06 – ALCANCE. O preceito do artigo 41 da Lei nº 11.340/06 alcança toda e qualquer prática delituosa contra a mulher, até mesmo quando consubstancia contravenção penal, como é a relativa a vias de fato.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ARTIGO 41 DA LEI Nº 11.340/06 – AFASTAMENTO DA LEI Nº 9.099/95 – CONSTITUCIONALIDADE. Ante a opção político-normativa prevista no artigo 98, inciso I, e a proteção versada no artigo 226, § 8º, ambos da Constituição Federal, surge harmônico com esta última o afastamento peremptório da Lei nº 9.099/95 – mediante o artigo 41 da Lei nº 11.340/06 – no processo-crime a revelar violência contra a mulher.”

(STF, HC nº 106.212/MS, Relator Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, v.u., j. 24.03.2011, RT vol. 100, nº 910, 2011, págs. 307/327).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SURSIS. NÃO CABIMENTO. ART. 77, III, DO CÓDIGO PENAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO ESTÁ A MERECER REPAROS. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. Não viola o princípio da colegialidade a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

apreciação unipessoal, pelo relator, do mérito do recurso especial, quando obedecidos todos os requisitos para a sua admissibilidade, bem como observada a jurisprudência dominante desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal.

2. Com a interposição do agravo regimental fica superada eventual violação ao princípio da colegialidade, em razão da reapreciação da matéria pelo órgão colegiado.

3. A prática de delito cometido com violência doméstica impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por conseguinte, incabível a aplicação do sursis, com base no disposto no art. 77, III, do Código Penal.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no AREsp nº 82.898/MG, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, v.u., j. 20.11.2012, DJe 26.11.2012).

“HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE DA LEI N.º 9.099/95. ORIENTAÇÃO DO PRETÓRIO EXCELSO NO SENTIDO DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 41 DA LEI N.º 11.340/2006. NÃO CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA À PESSOA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO INCISO I DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido da inaplicabilidade da Lei n.º 9.099/95 aos crimes praticados com violência doméstica ou familiar, em razão do disposto no art. 41 da Lei n.º 11.340/2006. Precedentes.

2. Incabível, na hipótese, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista que o Paciente não preenche o

requisito previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal, pois, não obstante a pena imposta tenha sido inferior a 4 (quatro) anos, trata-se de delito cometido com violência contra a vítima, o que impossibilita a pretendida substituição.

3. Ordem denegada.”

(STJ, HC nº 192.417/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, v.u., j. 06.12.2011, DJe 19.12.2011).

No mesmo sentido: STJ, HC nº 199.250/MS, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, v.u., j. 01.12.2011, DJe 14.12.2011; STJ, REsp nº 1.111.921/RJ, Relator Ministro Vasco Della Giustina [Desembargador convocado do TJ/RS], Sexta Turma, j. 16.08.2011, DJe 19.12.2011.

Por derradeiro, destaque-se que o regime prisional inicial semiaberto, para o recorrente Ivair, se mostra como o mais adequado à hipótese em tela, em observância dos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal, pela análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do mesmo “**Codex**”, conforme os fundamentos utilizados pelo MM. Magistrado de 1º Grau, na escolha do regime prisional: “*Diante da reincidência e dos maus antecedentes, fixo o regime inicial semiaberto (CP, art. 33).*” (fls. 139).

Na hipótese em tela, não obstante a reprimenda ter sido fixada em 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção, estão presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis — culpabilidade e circunstâncias do crime —, revelando-se adequado, à espécie, portanto, o regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça respalda o entendimento acima exposto:

“Esta Corte tem assentado que ‘em observação aos ditames do artigo 33, §§ 2º e 3º e do art. 59,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

ambos do Código Penal, presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis idôneas à elevação da pena-base acima do mínimo legal, adequado o regime prisional semiaberto para início de resgate da punição, ainda que o agente tenha sido condenado à pena inferior a quatro anos'. (AgRg nos EDcl no AREsp 384.010/RJ, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 03/02/2015)."

(STJ, AgRg no AREsp nº 550.501/SC, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, v.u., j. 30.06.2015, DJe 03.08.2015).

No mesmo sentido: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 384.010/RJ, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, v.u., j. 16.12.2014, DJe 03.02.2015; STJ, HC nº 299.321/SP, Relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, v.u., j. 25.08.2015, DJe 11.09.2015; STJ, HC nº 321.732/RJ, Relator Ministro Newton Trisotto (Desembargador convocado do TJ/SC), Quinta Turma, v.u., j. 01.09.2015, DJe 09.09.2015; STJ, HC nº 299.321/SP, Relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, v.u., j. 25.08.2015, DJe 11.09.2015.

Nega-se, pois, provimento ao recurso.

Consolidado o entendimento do Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária de 05 de outubro de 2016, daquele que prevaleceu no HC nº 126.292/SP (Relator Ministro Teori Zavascki), no sentido de que, exaurida a possibilidade de tramitação de recursos em Segunda Instância, ainda que pendentes Recursos Especial e Extraordinário sem efeito suspensivo, possível a determinação de início imediato do cumprimento da pena, determino a expedição de mandado de prisão após certificada a não interposição de recursos ordinários da presente decisão.

ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR